

1510396-74.2022.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510396-74.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510396-74.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Fato Atípico

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3030034/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 24492721 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CARLENSON MULLER PEREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

CARLENSON MULLER PEREIRA DOS SANTOS foi dado como incurso nas penas do art. 349-A do Código Penal, porque, no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 10h43, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária Dr Eduardo de Oliveira Viana, de Bauru, nesta cidade, ingressou com equipamento de comunicação móvel em estabelecimento prisional.

O réu foi citado (fls. 116).

Em audiência realizada em 25 de outubro de 2022, após apresentação de defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Na mesma oportunidade, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 119 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da

ação penal, nos termos da denúncia (fls. 123/125).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 128/131, alegando que: 1)- a perícia constatou que os celulares não estavam em funcionamento; 2)- a hipótese é de crime impossível; 3)- o réu agiu sob coação moral irresistível. Pediu a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04 e pelo auto de apreensão de fls. 05 (três mini aparelhos celulares de cor preta).

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída ao acusado.

Em juízo, a testemunha Rodrigo Marcos Rodrigues, agente de segurança penitenciária, relatou que o acusado voltava da saída temporária e passou pelo detector de metais. O aparelho "acionou positivo". O réu, então, foi submetido ao body scanner, o que é procedimento de praxe. Constatou-se que havia objeto suspeito no corpo dele.

Indagado, o réu confessou que havia ingerido três mini celulares. Ele foi isolado em cela de inclusão por algum tempo e expeliu os aparelhos voluntariamente. Viu os equipamentos expelidos. O acusado não explicou por que estava levando os celulares para dentro da prisão. Na mesma data, outros sentenciados também foram flagrados com mini celulares. Há seis celas no setor de inclusão, as quais são esvaziadas antes da saída temporária. Os detentos flagrados na posse de objetos ilícitos ficam isolados nessas celas depois de retornarem da saída temporária. Quando os presos se comprometem a expelir os itens de forma voluntária, ficam nessas celas e não são levados ao hospital para procedimento cirúrgico. No caso do réu, logo após passar pelo scanner, ele disse de pronto ter ingerido três mini celulares. Nessa situação os agentes anotam o ocorrido e o preso fica isolado. Após, o sentenciado é passado duas ou três vezes por dia no scanner. Também, sempre há um agente fiscalizando e aguardando os presos informarem que expeliram os itens proibidos.

A testemunha Emerson Jose Alves, também agente de segurança penitenciária, afirmou que, na data em questão, ocorria o retorno da saída temporária dos presos. Os detentos passavam pelo detector de metais. Quando o aparelho constatava algo suspeito, os sentenciados eram submetidos ao aparelho body scanner. O réu foi submetido ao scanner, quando se constatou que havia três placas metálicas na imagem. Indagado, o réu confessou que havia engolido três mini celulares. Ele foi colocado em cela de inclusão e entregou o material voluntariamente. O acusado não forneceu explicações. Não viu os objetos expelidos. O acusado os entregou a outro funcionário. Não chegou a vê-los nem posteriormente.

Interrogado em juízo, o réu declarou ter feito uma dívida na rua. Encontrou com o credor na unidade prisional. Ele estava coagindo-o e o ameaçando. Quando da saída temporária, o credor lhe deu os aparelhos, mandou que os ingerisse e que entrasse no presídio, para "morrer" a dívida. Devia a quantia de três mil reais. O débito foi contraído em 2014, quando estava solto. Foi preso em setembro de 2014. O credor permaneceu em liberdade. Em Bauru, não estava trabalhando quando estava no CPP. Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou ao menos que ingressou com os aparelhos celulares no presídio, após tê-los engolido.

Ademais, a prática do delito foi confirmada pelo depoimentos de dois agentes de segurança penitenciária, que submeteram o acusado ao aparelho de scanner corporal e constataram que havia algo em seu abdômen. Ainda segundo os agentes, o réu permaneceu em cela de inclusão até que, voluntariamente, expeliu os telefones celulares.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários: "(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Portanto, o fato descrito na denúncia e respectiva autoria estão bem demonstrados. Noutro aspecto, ao contrário do que alega a defesa, não há a necessidade de comprovação do funcionamento dos aparelhos mediante perícia para configuração do delito.

Nesse sentido:

"JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. ART. 349-A CP. INGRESSAR, SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MERA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA.CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 349-A DO CP. NON BIS IN IDEM. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E PENAL. SENTENÇA MANTIDA (...) 2. Trata-se de crime formal, o qual não exige outros desdobramentos para se caracterizar. O simples fato de o agente adentrar os portões do estabelecimento penal portando aparelho celular, sem autorização legal, já constitui o tipo penal (art. 349-A do CPB), ainda que a eficiência do objeto não tenha sido aferida por laudo técnico-pericial(não confeccionado), e mesmo que o aparelho não chegue ao contato de outros detentos, sendo ainda dispensável a prova de que o aparelho seria usado para fins ilícitos." (APJ 20150110399057. TJDF. 2ª T. Recursal. j. em 15/03/2017. Relator: João Fischer)

Ademais, pela própria lógica, é possível afirmar que os aparelhos eram aptos a funcionar.

O acusado não se submeteria ao risco de ser capturado em flagrante, ser apenado administrativamente e responder a processo criminal apenas para levar para o interior da unidade prisional telefone ineficaz para comunicação com o mundo externo.

Tampouco há que se falar em crime impossível, sob argumento de que, como todos os detentos são revistados ao entrar ou sair da unidade prisional, o réu não conseguiria introduzir o aparelho no presídio.

Na verdade, o acusado teria atingido sua finalidade se contasse com a conivência ou negligência dos agentes de segurança penitenciária.

Aliás, a própria experiência contradiz o argumento da defesa, pois se sabe que, constantemente, são encontrados aparelhos da espécie no interior de unidades prisionais.

Ainda, em caso análogo, assim se orienta a jurisprudência:

"Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por fragilidade probatória ou, quando não, pelo reconhecimento de crime impossível, ante a absoluta ineficácia do meio empregado pela ré para transportar o entorpecente para o interior do presídio, tendo em vista o procedimento de revista ao qual seria submetida. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação. Eficácia, ademais, do meio empregado pela

ré para a prática do tráfico. Reincidência específica, não reconhecida em primeiro grau, bem comprovada nos autos. Recurso ministerial provido, para aumentar as penas, e improvido o apelo defensivo." (TJSP, Apelação n. 0076838-45.2010.8.26.0224, rel.Sérgio Coelho, j. 29/11/2012).

A alegação de coação moral irresistível igualmente não pode ser acolhida.

A mera alegação de estar sendo coagido, sem outras provas para corroborar sua existência, não é suficiente para formar convicção a respeito.

Conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar cabia à defesa, e dele ela não se desincumbiu.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Art. 33 da Lei nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO PELA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A coação moral irresistível deve ser comprovada por quem a alega, nos termos do art. 156 do CPP, pois incumbe à defesa o ônus de provar eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva, tais como a excludente de culpabilidade alegada. A mera alegação não é suficiente para comprovar. (Apelação 0000049-06.2016.8.08.0059 - TJ ES - 1ª Câmara Criminal - Relator: Willian Silva).

Ademais, a versão do acusado, no sentido de que contraiu a dívida em 2014, quando estava em liberdade, e que foi coagido a transportar os aparelhos para dentro da prisão pelo credor (fato ocorrido em 2021), não soa verossímil.

Isto porque, se se tratasse mesmo de indivíduo perigoso e temido, que ao réu pudesse impor coação a ponto de fazê-lo cometer um crime mesmo quando estava cumprindo pena, teria ele conseguido buscar solução para seu crédito muito tempo antes.

Em suma, o acusado deve ser condenado nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, três meses de detenção.

O réu é reincidente (fls. 79 - art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal; e fls. 79/80 - art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal).

No entanto, confessou ao menos que trazia consigo os aparelhos celulares no interior da unidade prisional.

Entende o juízo que a atenuante da confissão, por dizer respeito à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

"Por envolver a personalidade dos agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência."

(HC n. 288.910/SP, 6a Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. Em 21/10/2014) (em TJSP, Apelação n. 0020654-38.2013.8.26.0071, j. 21/05/2015).

No caso concreto, no entanto, não se pode determinar pura e simplesmente a compensação integral entre a atenuante da confissão e a reincidência, pois, como visto, são duas as condenações anteriores a ensejar a agravante.

Nessa ótica, o melhor a fazer é desconsiderar apenas parcialmente o efeito das condenações pretéritas.

Nesse sentido:

"... não há como se operar a compensação integral ante a constatação de múltiplas reincidências. A melhor solução para a hipótese, a fim de não desprestigiar a confissão proporcionada pelos réus, é desconsiderar uma das condenações que caracterizam a reincidência e acrescer à pena patamar de aumento somente pelas condenações restantes." (TJSP, Apelação n. 0023777-06.2010.8.26.0344, rel. Salles Abreu, j. 28/02/2012).

Sendo assim, na segunda fase de aplicação da pena, considerando a reincidência múltipla e sua parcial compensação com a atenuante da confissão, eleva-se a pena na proporção de apenas um sexto, resultando em três meses e quinze dias de detenção.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Ante a reincidência, ensejada por duas condenações pretéritas, ambas por crimes cometidos com violência ou grave ameaça e uso de arma, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Carleson

Muller Pereira dos Santos como incurso nas penas do artigo 349-A do Código Penal, a cumprir três meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Quanto aos bens apreendidos, são daqueles cujas posses, por si sós, não configuram fato ilícito. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, os bens deverão ser doados ou inutilizados, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

P.R.I.

Bauru, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA